



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2018.0000697831

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0000063-60.2016.8.26.0197/50000, da Comarca de Francisco Morato, em que é embargante ADRIANO CAMPELO VITORIANO, é embargado COLENDIA 1ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.

ACORDAM, em 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram parcialmente estes embargos de declaração interpostos pelo réu Adriano Campelo Vitorino para que da decisão embargada constem as razões pelas quais se manteve a condenação do réu como incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal, sem reflexo no resultado final do julgamento. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores IVO DE ALMEIDA (Presidente) e PÉRICLES PIZA.

São Paulo, 10 de setembro de 2018.

MÁRIO DEVIENNE FERRAZ

RELATOR

Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Embargos de Declaração nº 0000063-60.2016.8.26.0197/50000 – 1ª Vara de Francisco Morato.

Embargante: ADRIANO CAMPELO VITORIANO

Embargado: Colenda 1ª Câmara de Direito Criminal

Voto nº 31.282.

1. Por sentença do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Francisco Morato, o réu Adriano Campelo Vitoriano foi condenado como incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal, a três meses e quinze dias de detenção, em regime prisional aberto, concedido o “*sursis*”, pelo prazo de dois anos, mediante condições, por ter, no dia 27 de setembro de 2015, por volta de 18h30min, na Avenida Ulisses Guimarães, nº 1971, Vila Guilherme, naquela cidade, ofendido a integridade corporal de sua ex-companheira Daiane Moraes Cavallaro, provocando-lhe lesão corporal de natureza leve.

Inconformado, o réu apelou em busca da absolvição por insuficiência de provas ou quanto ao dolo, alternativamente pretendendo o benefício da justiça gratuita, a exclusão da agravante reconhecida, a redução das penas e o afastamento do “*sursis*” fixado na sentença.

Esta Câmara, por decisão de 13 de agosto de 2018, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para afastar a agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal; reduzir as penas do réu a três meses de detenção, facultando-lhe, em sede de execução criminal, optar pelo cumprimento da pena carcerária ou recusar o benefício do “*sursis*” na audiência de advertência, bem como para lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

conceder a gratuidade da justiça (fls. 168/174).

Agora, sustentando haver contradição no acórdão, pois, *“ao recorrer da sentença monocrática, sustentou a necessidade de afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, e, por consequência, a exclusão do crime qualificado, no que se refere ao parágrafo 9º, do art. 129, do Código Penal”*, e *“o v. acórdão, ao afastar a agravante, terminou reconhecendo de forma contraditória a incidência do parágrafo 9º, do art. 129, embora tenha sido objeto das razões recursais que o crime não estaria entre aqueles classificados como relação doméstica, ou seja, tratando-se pois de mero crime de lesão corporal, eis que, quando dos fatos, restou incontroverso nos autos que as partes não mais viviam como marido e mulher”*, o réu Adriano Campelo Vitoriano interpôs embargos de declaração pedindo sejam providos para *“excluir a qualificadora do parágrafo 9º, do art. 129, do Código Penal e, conseqüentemente, dar baixa dos autos à origem para que seja possibilitada a transação penal”* (fls. 2/3).

É a síntese do necessário.

2. De início cabe observar que não há contradição no julgado embargado, porquanto a circunstância de ter sido afastada a agravante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal, não implicava, necessariamente, na desclassificação do delito pelo qual foi o embargante condenado para aquele do artigo 129, “caput”, do Código Penal. Por isso, nesse aspecto não comportam acolhimento os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Todavia, ficam eles acolhidos, em parte, para suprir omissão consistente na explicitação das razões pelas quais foi mantida a condenação do réu como incurso no artigo 129, § 9º, do mesmo diploma legal, a despeito da argumentação trazida no recurso de apelação, quanto à não caracterização de crime praticado no âmbito das relações domésticas por não mais conviverem réu e vítima sob o mesmo teto.

Nessa análise, é bem de ver que, ainda que o ora embargante estivesse separado da vítima por ocasião dos fatos, foi correta a condenação dele como incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal, em razão das lesões corporais nela causadas, pois essa norma alcança as lesões praticadas “*contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade*” (grifei).

A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “*Dispõe o art. 5º, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, que configura violência doméstica contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Inteligência da Súmula n. 600/STJ.*” (**HC nº 357.827-SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. em 16.08.2018**), pacificando a questão com a edição da Súmula nº

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

600, que dispõe: “*Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei n. 11340/2006 (Lei Maria da Penha) não se exige a coabitação entre autor e vítima*”.

Diante disso, cabe acolher em parte os embargos unicamente para declarar a decisão embargada, a fim de que dela constem estas razões pelas quais se manteve a condenação do réu como incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal, sem reflexo no resultado final do julgamento.

3. Destarte, pelo meu voto, acolhem-se parcialmente estes embargos de declaração interpostos pelo réu Adriano Campelo Vitorino para que da decisão embargada constem as razões pelas quais se manteve a condenação do réu como incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal, sem reflexo no resultado final do julgamento.

MÁRIO DEVIENNE FERRAZ

- Relator -